

1500234-74.2022.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... já foi condenado por fato análogo ao tráfico, quando adolescente, inviável para ambos os réus a redução de pena pelo tráfico privilegiado. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado. Requer o perdimento do dinheiro e veículos apreendidos em favor da União.

Em alegações finais, a Defesa do réu Emílio argumenta que não há provas suficientes do envolvimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1500234-74.2022.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500234-74.2022.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMILIO FERNANDES SOUZA e outro

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

EMILIO FERNANDES SOUZA e JOÃO PAULO MONTEIRO DA COSTA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, em 24 de janeiro de 2022, por volta das 11h00min, na Rua Hermes da Fonseca, nº 431, nesta cidade e Comarca, em concurso, conluiados e com unidade de propósitos, guardavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega ao consumo de terceiros, uma porção de cocaína, com peso líquido de 423,87 gramas (cf. laudos de constatação e químico-toxicológico às fls. 22/24 e 111/115).

Presos em flagrante delito (fl. 5), a prisão foi convertida em preventiva (fls. 82/84). Os réus foram notificados (fl. 1338 e fl. 1340) e apresentaram defesa

preliminar (fls. 1330/1333 e fls. 1334/1336). A denúncia foi recebida em 10/5/2022 (fls. 1346/1349) e os acusados foram citados (fls. 1392 e 1394).

Em audiência de instrução e julgamento virtual, realizada em 7/6/2022, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, uma testemunha de defesa e os réus foram interrogados (fls. 1403/1404).

Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia. Na fixação da pena devem ser considerados os maus antecedentes e reincidência do réu Emilio. Por tais motivos, e porque o réu João Paulo, apesar de primário, já foi condenado por fato análogo ao tráfico, quando adolescente, inviável para ambos os réus a redução de pena pelo tráfico privilegiado. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado. Requer o perdimento do dinheiro e veículos apreendidos em favor da União.

Em alegações finais, a Defesa do réu Emilio argumenta que não há provas suficientes do envolvimento do acusado com o delito, vez que nada de ilícito foi encontrado em seu poder, sendo flagrado somente por que deu carona ao réu João Paulo que, por sua vez, confessou a autoria do crime. Ainda pugnou pela restituição do veículo e, em que pese a recidiva, requereu sanção mínima com imposição de regime inicial abrandado (fls. 1407/1411).

Já o defensor de João Paulo, às fls. 1412/1422, diante da confissão do acusado, considerou legítima a postulação do Ministério Público. No que diz respeito à pena, pleiteou a aplicação de sanção mínima, além da incidência de atenuantes consistentes na confissão e no fato do réu ser menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos. Ainda requereu a aplicação do redutor relativo ao tráfico privilegiado na fração de metade, não sendo óbice a quantidade ou natureza da droga apreendida, além do regime aberto ou intermediário para cumprimento da pena, postulando a substituição da pena corpórea por restritivas de direito. Por fim, requereu a revogação da prisão cautelar.

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelas provas colhidas durante a instrução, tais como o auto de prisão em flagrante (fl. 5), boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão e fotos (fls. 16/17), foto (fl. 19), pelos laudos de constatação provisória e de exame químico-toxicológico – definitivo (fls. fls. 22/24 e 111/115), este atestando a natureza da substância apreendida (Cocaína) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Aldo Alessandro Pires e Márcio Cristiano Batista, policiais militares, declararam que na data dos fatos estavam em patrulhamento pela Zona Norte da cidade e, quando ingressaram na Rua Hermes da Fonseca, visualizaram o veículo dos réus. Ao avistarem a viatura policial os réus desembarcaram e tentaram correr para uma residência. Eles foram abordados e, em revista pessoal, com o réu Emilio havia um aparelho celular e R\$ 50,00. Com o réu João havia apenas um aparelho celular. No veículo, sob o banco do passageiro, havia uma sacola com um tablete de cocaína, com aproximadamente 500g e R\$ 26,00. Além disso, também havia outros materiais, aparentemente para serem misturados na droga, tais como fermento químico e carbonato de cálcio. Ao serem indagados sobre a propriedade da droga, nenhum dos réus se manifestou. Os réus eram conhecidos nos meios policiais pela prática do tráfico de drogas. Havia também informação de que um veículo Fiat/Pálio, verde ou azul, estava sendo utilizado para o tráfico.

A testemunha de defesa Jéssica Oliveira da Silva declarou que conhece o réu João Paulo há seis anos. Sabe que ele trabalhava com o pai em um bar e que é uma ótima pessoa e excelente pai.

O réu Emilio Fernandes Souza, interrogado, negou a prática do delito. Ele declarou que na data dos fatos emprestou o carro da sua mãe para lavá-lo e, quando passava na frente de um mercado, avistou o réu João Paulo, que pediu uma carona. Ele parou o carro e João Paulo entrou, com uma sacola que parecia ser de compra. Após este fato eles foram parados pela polícia militar e ele soube que dentro da sacola havia entorpecente.

O réu João Paulo Monteiro da Costa, interrogado, confessou ter adquirido entorpecente, que ele venderia em uma festa. Ele comprou outros materiais para misturar na cocaína e, quando saía do supermercado, encontrou com o réu Emilio, que lhe deu uma carona. Alguns minutos depois foram abordados pelos policiais militares, que encontraram o entorpecente.

Não obstante os argumentos defensivos, a atividade delitiva foi confirmada por um dos acusados e corroborada com a existência de elementos bastantes que demonstram que eram proprietários da droga e que a porção apreendida se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) a atitude suspeita dos acusados que, tão logo avistaram a viatura, deixaram o veículo e tentaram ingressar em uma residência próxima; b) a localização no interior do carro no qual estavam de um tablete de cocaína, além de substâncias variadas comumente utilizadas para a mistura e maior fracionamento da droga;

A prova coligida, por sua vez, é robusta e sustenta o decreto condenatório.

Com efeito, os policiais afirmaram de forma uníssona que ambos os acusados revelaram atitude suspeita quando a viatura se aproximou do carro no qual estavam. Os dois réus, que haviam deixado o veículo, tentaram adentrar às pressas na residência localizada na Rua América, nº 341, quando foram abordados.

De fato, como apontou a Defesa, nenhum deles morava no local (vide endereços de fls. 35 e 45) e a atitude de tentar se abrigar em residência desconhecida denota que sabiam da existência do entorpecente no interior do veículo e pretendiam se esquivar da abordagem policial.

Além disso, a carona aleatoriamente ofertada pelo réu Emilio ao acusado João Paulo e o seu completo desconhecimento em relação ao que ele trazia na embalagem plástica não encontra respaldo probatório nos autos, ao passo que a abordagem foi relatada de forma uníssona pelos policiais.

Denota-se que o acusado João Paulo no intuito de eximir o comparsa de qualquer responsabilidade, assumiu a propriedade da droga, dizendo inclusive que as demais substâncias apreendidas destinavam-se à "mistura" do entorpecente.

Sua versão não merece credibilidade ao passo que o réu Emilio igualmente tentou esquivar-se da abordagem, o que não seria necessário se desconhecesse realmente qual o conteúdo da embalagem plástica.

A par disso, o laudo pericial extraiu dados do celular pertencente ao sentenciado João Paulo e foi constatado no dispositivo, uma conta de usuário cadastrada no aplicativo WhatsApp no nome de "José", nome de usuário 5514997855774@s.whatsapp.net - fl. 169. Ainda concluiu por evidências entre os "chats" dos usuários "José" e "Vida" e dos usuários "Brunin" e "José" - fl. 170.

Destaca-se à fl. 411 o diálogo: "Nois vendeu 6 mil" e a resposta imediata do

usuário "José": "Tmj Jaja to aí".

À fl. 649 o usuário "Vida" alerta o réu João Paulo e menciona o nome do réu Emilio: "João o Emilio Flo que vc ia ser sacado" / "Eu fiquei sabendo" / "Pergunta pra ele".

Por fim, às fls. 739/740 indagado pelo usuário "Vida" onde foi, o usuário "José" responde: "Vim aqui na farmácia, compra umas parada". "Vai te que faze pó".

No mais, conquanto não afirmado em sede policial, quando indagados em Juízo pela própria Defesa, os dois agentes públicos declararam que havia notícias de que um veículo Fiat/Pálio, verde ou azul, estava sendo utilizado para o tráfico.

O fato é que diante das provas orais e documentais constantes dos autos, as versões dos acusados devem ser apreciadas com reserva, especialmente porque restaram completamente isoladas. Já em relação aos testemunhos dos policiais, destaco que seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, prestam conta de suas atividades, não havendo qualquer motivo para que incriminassem falsamente os detidos.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes em relação aos acusados, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade dos agentes, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Em relação ao réu Emilio Fernandes Souza, considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, ponderando, ainda, a quantidade de entorpecente apreendida e os maus antecedentes (processo nº 0023365-56.2010.8.26.0344 – pena cumprida em 21/11/2018 – fl. 63), exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), perfazendo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não há nos autos outros elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem nova majoração da pena-base.

Na segunda fase, agravo a pena em 1/6 em razão do réu ser reincidente (processo nº 0010340-24.2012.8.26.0344 – 2ª Vara Criminal do Foro de Marília/SP – pena extinta pelo cumprimento em 21/11/2018 – fls. 61/62), totalizando uma pena provisória de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Não há atenuantes da pena.

Na derradeira etapa, verifico que não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o réu ostenta antecedentes em crimes dolosos, inclusive condenado pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, não há prova nos autos de que o réu tem atividade remunerada lícita.

Mantenho, desta forma, a pena em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

No que diz respeito ao réu João Paulo Monteiro da Costa, considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal,

fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, porque, apesar da quantidade do entorpecente, o réu é primário (fls. 65/66). A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, como mencionado, o réu é primário e não há nos autos elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, não há circunstância agravante. Presentes as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, inciso I (agente menor de 21 anos na data do fato - fl. 47) e inciso III, alínea "d", do Código Penal (confissão espontânea). Contudo, não tem estas o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Por fim, não há causas de aumento de pena. Em que pese o acusado ser primário e ter bons antecedentes (fls. 65/66), deve ser levado em consideração o fato de que foi flagrado transportando quantidade expressiva de cocaína, droga de alto poder lesivo, além de substâncias utilizadas para o preparo de mistura que permite fracionamento em quantidade ainda maior. Além disso, agiu em concurso e com unidade de propósitos com o réu Emilio, o que denota, por si só, em razão do expressivo valor agregado - em torno de pelo menos 10.000,00 (dez mil reais) como por ele admitido em Juízo - envolvimento com organização criminosa e com o narcotráfico, motivo pelo qual deixo de aplicar a a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, devendo a reprimenda permanecer como dosada na primeira fase.

Torno assim final a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Pelas condições econômicas dos réus, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu Emilio Fernandes Souza, devidamente qualificado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa e o réu João Paulo Monteiro da Costa, devidamente qualificado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

A pena privativa de liberdade de ambos os réus deve ser cumprida em regime inicial fechado. Tratando-se de crime equiparado a hediondo, que causa consequências gravíssimas à sociedade, alimentando o crime organizado e destruindo as famílias dos dependentes químicos, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, a fim de que sejam atingidos os objetivos de prevenção geral e específica da punição criminal, especialmente pela expressiva quantidade de droga apreendida.

Além disso, verifico que, nos termos do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim os réus deverão iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, por não terem atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Também não há nos autos a comprovação necessária do requisito subjetivo para eventual detração e determinação do regime inicial de cumprimento da pena.

Anoto que, diante da pena fixada, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

Os réus tiveram a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante com quantidade expressiva de entorpecente, de nefasta repercussão social, permanecendo encarcerados durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram a custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva dos réus, que não poderão recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito de recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomendem-se os réus nos presídios em que se encontram recolhidos.

Em face da condenação supra, os sentenciados arcarão com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso sejam beneficiários da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Ademais, conforme o art. 91, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 63, da Lei Federal 11.343/2006, coadunados com o Tema 647 de Repercussão Geral do Excelso Pretório (REx 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17/05/2017), que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens, consistentes: I) no depósito judicial de fl. 116; II) 1 celular preto, marca Edmi, IMEI 8687550547315837; III) 1 celular Samsung de cor vermelha, IMEI 354622115062211 e; IV) 1 veículo Fiat – Palio ELX, ano/modelo 2000, cor azul, placas JPD-0114, chassis 9BD178269Y2200617

Ainda, nos moldes do art. 25, incisos I e II, e conforme o exposto permissivo do parágrafo único, inciso III, do mesmo preceptivo, coadunado com a parte final do art. 26, todos da Portaria 01/2020, assinada pelo Excelentíssimo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, autorizo a oportuna destruição dos bens antieconômicos.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal dos sentenciados, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e intime-se a Defesa pelo DJE, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 8 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA